

1500402-80.2019.8.26.0118

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIGI MONTEIRO SESTARI

Comarca: Cananéia

Foro: Foro de Cananéia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória por tráfico privilegiado. Recursos da defesa e da acusação. - Absolvição inadmissível.

Comprovadas autoria e materialidade. Conduta de ter em depósito e guardar, para o tráfico, um tijolo de maconha (peso líquido de 679,4g). Afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cananéia

Foro de Cananéia

Vara Única

Rua Pero Lobo, 75, Cananeia-SP - cep 11990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500402-80.2019.8.26.0118 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500402-80.2019.8.26.0118

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2185846/2019 - DEL.POL.CANANEIA, 5992686 - DEL.POL.CANANEIA, 526/19/101 - DEL.POL.CANANEIA, 2185846 - DEL.POL.CANANEIA, 526/19/101 - DEL.POL.CANANEIA, 2185846 - DEL.POL.CANANEIA, 526/19/101 - DEL.POL.CANANEIA, 2185846 - DEL.POL.CANANEIA, 526/19/101 - DEL.POL.CANANEIA, 2185846 - DEL.POL.CANANEIA, 526/19/101 - DEL.POL.CANANEIA, 2185846 - DEL.POL.CANANEIA, 526/19/101 - DEL.POL.CANANEIA, 2185846 - DEL.POL.CANANEIA, 526/19/101 - DEL.POL.CANANEIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS PATRICIO DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIGI MONTEIRO SESTARI

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia LUCAS

PATRICIO DE ARAUJO, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Consta da denúncia que:

“Consta do incluso inquérito policial, instaurado por auto de prisão em flagrante, que, no dia 26 de junho de 2019, por volta das 07h00, na Rua Praxedes Matheus de Oliveira, n.º 121, bairro Carijo, nesta cidade e comarca de Cananéia, LUCAS PATRÍCIO DE ARAÚJO, qualificado às fls. 16, guardava, para a entrega e consumo de terceiros, 07 barras intactas e 01 barra quebrada de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como “maconha”, pesando aproximadamente o total 81,0g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 05/06 e laudo pericial de fls. 55/57) Noticiam os autos que LUCAS guardava em sua residência a droga acima descrita, com fim de vendê-la e entregá-la para terceiros. Contudo, na data dos fatos, policiais civis deram cumprimento ao mandado judicial de busca e apreensão domiciliar expedido em desfavor do denunciado, nos autos n.º 1500384-59.2019.8.26.0118. Durante a diligência, localizaram no interior da geladeira da residência a droga acima descrita, embalada para o comércio, bem como, em um recipiente metálico ao lado da substância, a quantia de R\$ 200,00, em notas de R\$100,00, R\$50,00, R\$20,00 e R\$10,00. As circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão, a quantidade de droga apreendida, bem como o dinheiro encontrado, em notas fracionadas, indicam que as drogas apreendidas na residência do denunciado se destinavam à comercialização e à entrega a terceiros.”

A denuncia foi recebida em 24 de outubro de 2019 (fls. 76/77).

O acusado foi citado em cartório em 19/11/2019 (fls. 84) e apresentou defesa prévia (fls. 87/88).

Foi ratificado o recebimento da denúncia e designada primeira audiência de instrução e julgamento (fls. 97/98).

Em audiência realizada em 09/03/2022, foram ouvidas as testemunhas bem como realizado o interrogatório do acusado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

Pelo Ministério Público a pretensão punitiva do Estado é procedente, devendo o réu ser condenado nos exatos termos da prefacial acusatória.

A defesa, por sua vez, a acusação não merece prosperar, que as testemunhas não corroboram as alegações prestadas em fase de inquérito policial, pediu a absolvição do acusado.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente à análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06, do Código Penal.

Passo a análise da prova oral produzida.

A materialidade delitiva resultou provada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/7), auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), das fotografias de fls. 30/31, do laudo de constatação provisório (fls. 10/11), do laudo definitivo de fls. 58/60 e do laudo pericial dos objetos apreendidos de fls. 66/68.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação.

A testemunha ONÉSIO VERISSIMO FILHO, policial civil condutor, em solo policial (fls. 12/13) relatou “que durante operação Judiciária Deinter-6 Santos e em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1500384-59.2019.8.26.0118 pela Comarca de Cananeia-SP, diligenciaram, juntamente com a Autoridade Policial, ao endereço de Lucas Patricio de Araujo, localizado na rua Praxedes Matheus de Oliveira nº 121, bairro Carijo em Cananeia-SP. Que no local, em contato com Lucas Patrício, foi dado ciência do referido mandado e iniciada as buscas na residência. No interior da geladeira foi localizado, em um invólucro de borracha 07 barras intactas e uma barra quebrada de maconha (com peso de 81

gramas), todas embaladas para o comércio, bem como, em um recipiente metálico ao lado contendo R\$ 200,00 reais em notas de R\$ 100,00, 50,00, 20,00 e 10,00. O Depoente informou ainda que na data de 12/06/2019 foi preso em flagrante a pessoa de Gabriel da Silva Gomes Calasans pelo crime de tráfico de drogas e receptação (inquérito policial nº 2173909 e RDO nº 484/2019) e naquela oportunidade em Termo de Interrogatório Gabriel noticiou que a pessoa de Lucas Patrício de Araujo comercializa drogas diariamente na casa onde Lucas reside e que tais drogas ficavam escondidas no interior da geladeira, exatamente como foi localizada as drogas, nesta data, pela Policia Civil durante o cumprimento do referido mandado. Diante de tais fatos a Autoridade Policial deu voz de prisão ao indiciado Lucas Patricio de Araujo pelo crime de tráfico de drogas e determinou a condução da ocorrência a esta Delegacia de Polícia."

Em juízo, ONESIO VERISSIMO FILHO relatou que se recorda da diligência de cumprimento de busca e apreensão na residência de LUCAS, uma vez que havia uma denúncia de que Lucas traficava em sua casa, na residência foram localizadas drogas na geladeira e R\$200,00 (duzentos reais) em notas diversas, sendo o acusado conduzido a delegacia e que em seu interrogatório relatou que era usuário pesado de drogas, que também foram encontrados sacolés (chups-chups), os quais são usados para a embalagem de entorpecentes. Desconhece que o acusado seja traficante, que nunca o abordou e não ouviu o nome dele como traficante.

Já a testemunha JOSÉ GALDINO PEREIRA NETO, também policial civil, disse na fase extrajudicial (fl.14) que "durante operação Judiciária Deinter-6 Santos e em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1500384-59.2019.8.26.0118 pela Comarca de CananeiaSP, diligenciaram, juntamente com a Autoridade Policial, ao endereço de Lucas Patricio de Araujo, localizado na rua Praxedes Matheus de Oliveira nº 121, bairro Carijo em Cananeia-SP. Que no local, em contato com Lucas Patrício, foi dado ciência do referido mandado e iniciada as buscas na residência. No interior da geladeira foi localizado, em um invólucro de borracha 07 barras intactas e uma barra quebrada de maconha (com peso de 81 gramas), todas embaladas para o comércio, bem como, em um recipiente metálico ao lado contendo R\$ 200,00 reais em notas de R\$ 100,00, 50,00, 20,00 e 10,00. O Depoente informou ainda que na data de 12/06/2019 foi preso em flagrante a pessoa de Gabriel da Silva Gomes Calasans pelo crime de tráfico de drogas e receptação (inquérito policial nº 2173909 e RDO nº 484/2019) e naquela oportunidade em Termo de Interrogatório Gabriel noticiou que a pessoa de Lucas Patrício de Araujo comercializa drogas diariamente na casa onde Lucas reside e que tais drogas ficavam escondidas no interior da geladeira, exatamente como foi localizada as drogas, nesta data, pela Policia Civil durante o cumprimento do referido mandado. Diante de tais fatos a Autoridade ADEMICIO BERNARDO MUNIZ DA SILVA Policial deu voz de prisão ao indiciado Lucas Patricio de Araujo pelo crime de tráfico de drogas e determinou a condução da ocorrência a esta Delegacia de Polícia."

Perante este juízo JOSÉ GALDINO PEREIRA NETO, relatou que foi convocado para uma diligência policial, na qual iria cumprir um mandado de busca e apreensão na casa de Lucas Patricio, pois havia uma denúncia de um preso chamado Gabriel informando que o acusado traficava drogas e a guardava dentro da geladeira, afirma que foi encontrada as drogas na geladeira, dinheiro e não se recorda quais objetos foram apreendidos, que não conhecia o acusado. Disse que estava somente no apoio à diligência de busca e apreensão de drogas que era guardada na geladeira da residência do acusado.

A Testemunha de defesa GABRIEL DA SILVA CALAZANS relatou que não é parente do acusado e o desconhece, não sabe se ele comercializa drogas, não sabe dos fatos e não confirma seu depoimento na delegacia, afirma que conhece Ademicio Bernardo e não se recorda dos fatos.

A testemunha de defesa ADEMÍCIO BERNARDO MUNIZ DA SILVA relatou que conhece o acusado da escola, que não se recorda dos fatos e nunca imaginou que o acusado traficasse drogas, afirma que nunca morou com o acusado, que não sabe o motivo do Gabriel ter falado sobre os fatos.

A informante ANA ROSA PATRÍCIO, genitora do réu, afirmou que à época dos fatos o seu filho usava maconha e disseram para ele que se ele guardasse as drogas na

geladeira seriam mais bem conservadas. Afirmou que ele comprava as drogas com o dinheiro que ela dava, não para esse fim, mas ele economizava sua mesada para comprar maconha.

Em seu interrogatório em solo policial (fl. 15), o acusado declarou que "é usuário 'pesado' de maconha, e devido a isso mantém sempre uma quantidade 'boa', destinada a seu uso. Que seu vício é mantido pela sua mãe, que lhe dá dinheiro para comprar e que o dinheiro apreendido R\$ 200,00 (duzentos reais) foi sua mãe que lhe deu, pois sua maconha estava acabando e precisava comprar mais. Que se recusa a dizer de quem compra sua droga. Quanto aos saquinhos tipo 'chup chup' apreendidos estes seriam usados para fazer sorvete no verão."

Em juízo, o acusado LUCAS PATRÍCIO DE ARAÚJO relatou que as drogas encontradas em sua casa eram para uso próprio, pois era usuário pesado de maconha, que ia no ponto de tráfico e comprava, não trabalhava e arrumava dinheiro com sua mãe e avó, diz que não gastava todo o dinheiro com as drogas, que sua mãe lhe dava R\$20,00 a R\$30,00 por semana, não soube informar quanto valia as drogas encontradas em sua residência, que os saquinhos de chup-chup eram para fazer sacolés, quem os fazia era sua mãe, afirma que não conhecia GAABRIEL CALANZAS e conhecia ADEMICIO da escola, e que ele já tinha ido na sua casa, ADEMICIO o viu guardando a droga na geladeira.

No caso dos autos, a alegação do réu de que seria usuário de drogas é elemento isolado dos autos, frente ao conjunto probatório, notadamente o testemunho dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante quando encontraram, no interior da residência do réu LUCAS, as drogas apreendidas em barras dentro da geladeira, local que havia sido indicado pela testemunha Gabriel Calanzas quando de seu depoimento na delegacia, o qual originou a diligência por meio de mandado de busca e apreensão autorizada pela Polícia Judiciária.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. E o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras.

Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

A jurisprudência segue igualmente:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

"Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ AC Rel. Synésio de Aquino RDTJR 7/287).

"Não faz sentido repudiar testemunho por provir de agente da polícia. Ao contrário, sua palavra deve ser avaliada e aceita a partir de sua função social que, por isto mesmo, se impõe com o peso mais contundente do que o cidadão comum" (in "Jurisprudência Penal e Processual Penal", AZEVEDO FRANCESCHINI, vol. 8, pág. 386).

O réu guardava e tinha em depósito diversas quantidades de drogas, notadamente 7 barras intactas e uma quebrada de "maconha", juntamente com sacolés (chup-chup), embalagens essas usadas para embalar os entorpecentes, bem como em sua posse foram apreendidos R\$ 200,00 (duzentos) em dinheiro em notas diversas, o que denota a mercancia dos entorpecentes.

Portanto, a alegação de que era usuário "pesado" de maconha não encontrou respaldo em nenhuma prova dos autos.

A um, já que não foram encontrados instrumentos usualmente utilizados por usuários de maconha, como dichavadores, piteiras, papéis de seda, "boladores", tabaco, etc. A dois, já que as provas dos autos demonstraram a existência de mercancia,

denotando tráfico, tanto pela quantidade de droga (7 barras de 80 gramas aproximadamente), forma de acondicionamento (barras grandes), notas de dinheiro diversificadas e sacolés (chup-chup) utilizados para embalagem da droga. Tal fato é corroborado pelo laudo pericial dos objetos apreendidos de fls. 66/68, informando que os objetos apreendidos poderiam ser utilizados para o acondicionamento de drogas.

A três, já que o próprio réu em seu interrogatório não soube sequer informar a este juízo quanto pagou pelas supostas drogas que utilizava para seu uso próprio, o que se afigura contraditório com a tese de que seria usuário, ou seja, comprador contumaz de maconha.

É a jurisprudência pacífica deste E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Validade do depoimento dos policiais – Circunstâncias da apreensão, aliadas à diversidade e natureza das drogas, bem como à presença de dinheiro, que evidenciam a destinação à mercancia – Descabida a desclassificação perseguida – Condenação bem decretada – Penas acertadamente dosadas – Não caracteriza 'bis in idem' a valoração de uma condenação definitiva como circunstância desfavorável, na primeira fase, e, de outra, como agravante, na segunda etapa do itinerário trifásico – Caracterizada a recidiva, a fração de acréscimo se afigura como discricionariedade do magistrado – Incremento em patamar superior ao de 1/6 que se apresentou adequado, notadamente em razão da multirreincidência – Precedente – Recidiva que obsta a aplicação do redutor disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 – Persistência da majorante elencada no art. 40, VI, da Lei de Drogas – Idades dos menores comprovadas por meio do boletim de ocorrência – Validade – Precedente – Regime prisional fechado único adequado à espécie – Detração penal – Descabimento – Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500049-98.2020.8.26.0540; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/05/2021; Data de Registro: 11/05/2021)

Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado em conhecido ponto de mercancia espúria em poder de 53 porções de cocaína, pesando 38,7 gramas, 20 porções de maconha, com peso de 43,9 gramas, e 20 pedras de crack, pesando 4,3 gramas, além da quantia de R\$ 122,00. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares.

Confissão do acusado. Diversidade de drogas que confirmam a posse para fins mercantis. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à fração máxima. Imposição de regime aberto. Cabível substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Parcial provimento ao apelo defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 0001132-63.2018.8.26.0616; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/02/2021; Data de Registro: 05/02/2021)

No tocante à tipicidade, é assente na doutrina e na jurisprudência que para a caracterização do crime de tráfico de drogas não é necessário que haja provas da comercialização, ou que o réu venha, de fato, a vender entorpecentes, bastando que pratique quaisquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista tratar-se de tipo misto alternativo, de ação múltipla ou de conteúdo variado, que traz dezoito verbos distintos, sendo certo que, no presente caso, o acusado incorreu na prática do núcleo do tipo “guardar e ter em depósito” com o intuito de dispensar as drogas no mercado ilícito.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. TJSP:

Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Impossibilidade. Quantidade da droga e forma de acondicionamento que evidenciam a prática da traficância. Reconhecimento do delito em sua modalidade tentada. Não cabimento. O tráfico de drogas é tipo penal misto alternativo. Possuindo 18 ações distintas, o delito se consuma com a prática de um

dos núcleos do tipo penal. A conduta "trazer consigo" é delito de mera conduta, que não admite a modalidade tentada. Aplicação do redutor do §4º do artigo 33, da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima. Quantidade de droga apreendida que não pode ser considerada expressiva tendo em vista o local de cometimento do delito - a cidade de São Paulo. Fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em face da quantidade de pena aplicada e da primariedade do agente. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0001899-83.2014.8.26.0635; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/12/2015; Data de Registro: 04/12/2015)

Bem explica a diferença no dolo do tipo do tráfico (congruente ou congruente simétrico) e do porte para consumo pessoal (incongruente ou congruente assimétrico) o eminente Desembargador MENS DE MELLO (Apelação Criminal nº 1501342-

91.2020.8.26.0544, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. em 15/02/2022), verbis:

Neste sentido, o crime de tráfico de entorpecentes, em ambas as leis, é um tipo misto alternativo, onde a narrativa se ajusta ao que está entre as formas

elencadas. Assim, as condutas de trazer consigo, guardar, transportar etc. não exigem especial fim de agir. É um tipo congruente, conforme MIR PUIG, MAURRACH E

JAKOBS, ou congruente simétrico, conforme ZAFFARONI. O tipo congruente, ou

congruente simétrico, caracteriza-se pela exigência de congruência entre os aspectos objetivo e subjetivo, no sentido de que contenha apenas o querer a

realização do tipo objetivo (dolo natural). Assim, nas figuras de adquirir, guardar, trazer consigo, transportar, entre outras, basta que não exista a

finalidade do exclusivo uso próprio, presente no tipo do artigo 16 da Lei 6.368/76 e artigo 28 da Lei 11.343/06, para que se configure a tipo subjetivo do crime de

tráfico de entorpecentes. Ou seja, apenas o artigo 16 da Lei 6.368/76 e artigo 28 da Lei 11.343/06 é que são tipos incongruentes, conforme MIR PUIG, MAURRACH E

JAKOBS, ou congruente assimétrico, na terminologia de ZAFFARONI. Desta forma, nas condutas presentes no porte e no tráfico, como trazer consigo, existindo elementos

que excedem ao dolo, os chamados elementos subjetivos do injusto (no caso a finalidade específica da destinação ao consumo pessoal), estar-se-á configurado o

porte. Não existindo tal finalidade específica, ou seja, não se destinando exclusivamente ao consumo pessoal, não importando qual a finalidade, tem-se por

configurada a figura do tráfico de entorpecentes.

Desse modo, a conduta do réu se subsume perfeitamente ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, já que a defesa não demonstrou a finalidade

específica da guarda das drogas para consumo pessoal, pelo contrário, o Parquet fartamente demonstrou se tratar de caso de traficância.

Assim sendo, estão devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do fato que sobre ele recai.

Ainda, aplica-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que preenchidos todos os requisitos para tanto, pois o acusado é primário e não possui antecedentes (fls. 38), bem como não há provas de que se

dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Na espécie, foi apreendida vultosa quantidade de droga (maconha), no entanto, quantidade esta que não impede a aplicação do redutor na terceira fase, posto não

configurar o requisito de dedicação à atividade criminosa.

Ademais, o réu LUCAS, ao que se demonstrou da prova oral colhida nos autos, notadamente de seu próprio interrogatório e do testemunho dos policiais civis, não

atua no crime, não podendo ser considerado, pelos elementos colhidos nos autos, como alguém dedicado à atividade criminosa.

Em caso análogo, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória por tráfico privilegiado. Recursos da defesa e da acusação. - Absolvição inadmissível.

Comprovadas autoria e materialidade. Conduta de ter em depósito e guardar, para o tráfico, um tijolo de maconha (peso líquido de 679,4g). Afastamento do redutor do

art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Quantidade e natureza que não comprovam estivesse o réu dedicado à atividade criminosa ou que integre organização criminosa.

Desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas incabível. Confissão espontânea

condizente com as provas dos autos. Réu primário e de bons antecedentes. Penas e regime aberto compatíveis. Aplicação do art. 44 do Código Penal. Compatível. Precedentes. – Recurso ministerial desprovido; recurso da defesa parcialmente provido, nos termos do v. Acórdão. (TJSP; Apelação Criminal 1501044-77.2020.8.26.0228; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. Ordem concedida para determinar ao Juízo de origem que refaça a dosimetria com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada. (HC 195319 AgR, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 04-03-2021 PUBLIC 05-03-2021)

Por não haver qualquer circunstância que o impeça, a redução deverá se dar em seu grau máximo, qual seja, em dois terços (2/3).

Por fim, o acusado era imputável na data dos fatos, tinha consciência do caráter ilícito de sua conduta, e não há quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais de que trata o art. 59 do Código Penal e atento às circunstâncias preponderantes elencadas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que, no que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a reprovação social da conduta do agente, não há motivos para maior valoração da pena. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, o acusado não possui condenação anterior, sendo, portanto, réu primário e sem antecedentes. No que diz respeito à conduta social, deve ser valorada pelo desempenho do réu na sociedade, na família e no trabalho, e não em relação aos fatos criminosos e atos infracionais supostamente cometidos. Dessa forma, por não haver nos autos qualquer informação acerca da convivência social do acusado, não há elementos para valoração da conduta social. Na análise do vetor circunstâncias, previsto no art. 59 do Código Penal, deve ser apreciado o disposto no art. 42 da Lei de Drogas: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, foi apreendida pequena quantidade de droga (maconha), notadamente 81 (oitenta e uma gramas), quantidade esta que não enseja majoração da pena-base, nem impede a aplicação do redutor na terceira fase, consoante jurisprudência deste E. TJSP em casos semelhantes (Apelação Criminal 1501044-77.2020.8.26.0228; Relator OSNI PEREIRA; 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2021 e Apelação Criminal nº 0001132-63.2018.8.26.061, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. GUILHERME DE SOUZA NUCCI, julgado em 05/02/2021). Os motivos são inerentes ao próprio tipo violado, porquanto o agente, em tal conduta, visa a obtenção de lucro fácil, não se importando com o mal que o usuário e destinatário da droga possa sofrer. As consequências do ilícito são gravíssimas, em razão da má repercussão e da influência nefasta que esta modalidade delituosa exerce, especialmente, sobre os adolescentes, com resultados desastrosos nos núcleos familiares, com sua desestruturação e/ou muitas vezes, com sua destruição.

A droga é causa de morte prematura de muitas pessoas em todo o mundo, de forma que tal espécie de crime merece pronto e eficaz combate da sociedade, mediante reprimenda exemplar para coibir sua prática. Entretanto, tais argumentos já foram considerados pelo legislador penal quando da elaboração do preceito secundário. Quanto à personalidade do agente, refere-se a um conjunto somatopsíquico (ou psicossomático), exigindo formação técnica. No caso, não há dados nos autos para aferição desta circunstância. Por fim, ante a natureza do delito, não há falar-se em comportamento da vítima. Sopesadas tais circunstâncias, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não vislumbro a presença de atenuante ou agravante, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase, não há nenhuma causa de aumento de pena a ser aplicada, o acusado é primário, possui bons antecedentes, e não há provas de que se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Assim, aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, reduzindo a pena em dois terços (2/3), estabelecendo a pena definitiva em de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando a ausência de informações precisas acerca da situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (art. 49, § 1º, do Código Penal e 43 da Lei 11.343/2006).

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§2º e 3º do Código Penal).

Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, incluindo-se aí o tráfico de drogas, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c/c o art. 59, ambos do Código Penal e nas Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719/STF.

Vide para tanto a ementa:

Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. 1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na vigência da Lei nº 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados. 2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. 3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o semiaberto. 4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal. 5. Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que “[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado”. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado. (HC 111840, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,

julgado em 27/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 16-12-2013 PUBLIC 17-12-2013)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1052700, com REPERCUSSÃO GERAL, julgado em 02/11/2017, considerando inconstitucional a fixação ex lege do regime inicial fechado com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. (ARE 1052700 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Assim, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e primariedade do agente, fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena, tudo na forma do art. 33, § 2º, "c" do Código Penal, mediante o cumprimento das condições elencadas no art. 115 da Lei de Execuções Penais.

Destaco que deixo de aplicar a detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a matéria é afeta ao Juízo da Execução, posto que ausente requisito subjetivo nos autos para tanto.

A pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, o delito não foi cometido mediante violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais são favoráveis. Por isso, forte no art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em:

a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, em entidade assistencial ou outro estabelecimento congênere, a ser indicado pelo Juízo da execução, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, § 3º, do Código Penal); e,
b) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no valor de 01 (um) salário-mínimo. A forma de pagamento da prestação pecuniária será estabelecida em audiência admonitória a ser oportunamente designada.

Trata-se das medidas restritivas que se mostram mais consentâneas às circunstâncias que norteiam o fato praticado e às condições pessoais do réu, haja vista que esta Comarca não dispõe de local adequado para cumprimento da pena de limitação de fim de semana, sendo certo que o cumprimento desta medida em prisão domiciliar não atende às finalidades da pena, por não haver qualquer fiscalização.

Ante a substituição acima operada, fica prejudicada a análise do cabimento da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Ante o exposto, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado LUCAS PATRÍCIO DE ARAÚJO, por ter praticado fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º

11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial ABERTO, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e b) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Considerando que o réu foi condenado ao cumprimento da pena em regime aberto e que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, entendo que não há razoabilidade em se manter as medidas cautelares outrora impostas (art. 387, § 1º, CPP). Assim, REVOGO AS MEDIDAS CAUTELARES anteriormente fixadas (fls. 44/45).

Condeno o sentenciado também ao pagamento das custas e despesas processuais.

No caso, considerando que compete ao acusado a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006) e ausente tal comprovação, DECRETO O PERDIMENTO dos valores apreendidos R\$ 200,00, devendo ser revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Após o trânsito em julgado:

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06;

Com relação à pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art.

336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);
Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;
Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;
Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;
Ofícios de praxe;
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Cananeia, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA